

1500550-04.2022.8.26.0210

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... é equiparado aos hediondos.

O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais.

Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.

Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500550-04.2022.8.26.0210 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500550-04.2022.8.26.0210

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Roberto Aparecido Schentl

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. MARCOS ROBERTO APARECIDO SCHENTL, qualificado a fls. 15, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 12 de

julho de 2022, por volta das 14h, na Avenida 7B nº 75, Bairro Jardim Amélia, nesta cidade e Comarca, teria trazido consigo e teria em depósito, com finalidade de traficância e entrega ao consumo de terceiros, cinquenta e nove microtubos contendo cocaína, com peso líquido de 45 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

É da denúncia que “na data dos fatos, policiais militares receberam notícia de que o denunciado possuía drogas em sua residência para posterior comercialização. Diante da informação, dirigiram-se até a residência dele e, após autorizados a ingressaram no local pelo genitor de MARCOS, foram até o seu quarto e o encontraram sentado na cama.

Os policiais, então, realizaram uma busca no cômodo e localizaram, embaixo da cama, 55 (cinquenta e cinco) pinos contendo 'cocaína'.

Diante da situação, promoveram a prisão em flagrante do denunciado e o conduziram até a Delegacia de Polícia, local em que MARCOS foi submetido a uma busca pessoal e apreendido em seu poder mais 4 (quatro) pinos contendo 'cocaína'.”.

A denúncia de fls. 64/66 foi recebida em 10 de agosto de 2022 (fls. 68), sendo o Réu citado (fls. 98), apresentando defesa preliminar em fls. 79/91, rejeitada em fls. 101/103. Durante a instrução foi colhida prova oral e interrogado o Réu (fls. 123).

Em memoriais, o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 121/122).

A douta Defesa, por seu turno, requereu a improcedência da ação, alegando a inexistência de provas que indicassem ser o Réu narcotraficante, sustentando, de outra forma, nulidade por invasão domiciliar dos policiais pleiteando a absolvição do Acusado e, subsidiariamente, caso condenado, requereu fixação da pena no piso, em regime aberto para cumprimento, garantindo, ademais, o direito de recorrer em liberdade (fls. 124/139).

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está estampada no auto de prisão em flagrante de fls. 01/05, no boletim de ocorrência de fls. 06/07, auto de exibição e apreensão de fls. 09, auto de constatação preliminar de fls. 10, pelo laudo de exame químico-toxicológico a fls. 57/59, além da prova oral colhida durante a instrução.

A autoria é certa contra o Réu que em Juízo negou o teor da acusação, sustentando que estava em sua casa dormindo quando os policiais ingressaram e o acordaram dizendo que havia droga ali, o que por ele foi negado, de forma que revistaram a residência e nada encontraram, com o que ele ainda falou para que procurassem debaixo da cama, o que foi feito e, então, localizado o entorpecente, que, contudo, não era seu e desconhece como foi parar ali. Ademais, era usuário de crack e cocaína, não havia mulher na casa e seu pai não autorizou o ingresso dos policiais.

Sua versão não convence e ficou isolada do contexto probatório colhido nestes autos.

O policial militar Carlos, na fase judicial, alegou que tinham a informação de que o Réu guardava bens furtados e drogas em sua residência, para lá se deslocando, conversando com o genitor do Acusado, que autorizou que entrassem na casa, dirigindo-se ao quarto do Acusado, que estava sentado na cama e, em revista, encontraram sob o leito as porções de cocaína depois de breve revista no Réu,

quando nada localizaram, de forma que o conduziram até a delegacia, onde realizaram busca minuciosa e encontraram outros quatro pinos de cocaína, idênticos ao que estava debaixo da cama. Ademais, o Réu nada quis falar naquele momento, é conhecido dos meios policiais também pelo tráfico e não aparentava ter feito uso de droga. Por fim, disse que tanto o Acusado quanto seu pai acompanharam as buscas. Em linhas gerais, este foi o teor do depoimento do policial Bruno.

A conduta do Acusado, pois, indica que no dia, horário e local apontados na denúncia, trazia consigo e tinha em depósito substância entorpecente para fins de traficância. A isso se chega com a prova coligida aos autos, notadamente a considerável quantidade de droga encontrada com o Réu, não estava sob efeito de drogas, ademais, é conhecido dos meios policiais também pela traficância, não tendo dado qualquer indicação crível de onde teria surgido o entorpecente. Tais condutas apontam que o Réu utilizava o entorpecente apreendido consigo para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343, de 23.08.2006. Importante destacar que o simples fato de ser usuário de drogas – sequer comprovado – não inibiria a conduta do narcotráfico, sendo que, muitas vezes, tais condutas caminham juntas.

Nem se olvide pelo fato de a acusação se embasar somente no depoimento prestado por policiais, que é válido e está em consonância com as demais provas, sem existência de qualquer indicativo de sua imprestabilidade, não podendo ser descartados, notadamente porque o Réu, conforme sobredito, não ofertou qualquer resistência ao depoimento deles.

A condição funcional não os torna suspeitos, valendo, outrossim, o princípio de presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados. Nesse diapasão, “Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que inocorreu nos autos.

Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram” (TJSP, Ap. 990.08.168537-0, 10ª C.D.Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. 16.04.2009).

Assim, tem-se a declaração isolada do Réu dada em Juízo que, por motivos óbvios, possui intenção de se isentar das penas da narcotraficância e, de outro lado, o depoimento uníssono dos policiais militares, agentes públicos que contaram com detalhes a prisão do Réu, nada sendo levantado e muito menos comprovado contra eles, de forma que viesse a colocar em xeque seus depoimentos.

Ressalto, de outro lado, que não se pode falar em invasão de domicílio pelos policiais, considerando que o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 10.343/06 é classificado como permanente, de modo que a consumação se arrasta no tempo e permite a prisão em flagrante a qualquer momento. Sendo assim, não era necessária autorização judicial para ingressar na residência em que se encontrava o Acusado, mormente porque o genitor do Acusado, ao que consta também morador do local, anuiu ao ingresso dos policiais em sua residência, nada havendo em sentido contrário, agindo os agentes policiais, portanto, dentro da exceção à regra constitucional da inviolabilidade do domicílio, insculpida no artigo 5º, inciso XI, da CF/88: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou

para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” (destaquei).

Importante ressaltar que não há qualquer indicativo de que o Réu não tivesse integral consciência do ilícito, porquanto o documento de fls. 91 não indica que ele fosse inimputável ou mesmo semi-imputável, porquanto é um demonstrativo de que ele já passou por clínica de reabilitação, mas que concluiu o tratamento em 30.01.2021, um ano e meio antes da data do fato descrita na denúncia.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade. Sendo assim, reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

O Acusado ostenta antecedentes, consistente em condenação criminal em Primeira Instância (fls. 29/30, autos nº 1500027-89.2022.8.26.0210) e que pode ser utilizada sem risco de incorrer em bis in idem com a reincidência porque são processos distintos, o que demonstra personalidade persistente na prática de condutas antissociais e exige resposta estatal mais vigorosa, razão pela qual, atendendo aos critérios dos artigos 59 e 60 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, com o que promovo o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) e a fixo em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor patamar, à míngua da comprovação de suas condições financeiras.

Na segunda fase da dosimetria da pena, aumento-a em 1/5 (um quinto) em razão da reincidência (cf. fls. 30, autos nº 1501137-31.2019.8.26.0210), atingindo o patamar de 7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa.

O Acusado não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que a forma como se desenhou os fatos, sendo ele, portador de antecedentes e reincidente, conhecido pela traficância, vem a demonstrar que se dedica, indubitavelmente, à atividade criminosa do tráfico de drogas, tanto que não demonstrou possuir ocupação lícita.

Nesse diapasão: “Para redução da pena, essencial que o réu seja 'primário', apresente 'bons antecedentes', comprove que 'não se dedique às atividades criminosas', assim como, 'nem integre organização criminosa'.

Evidente que essa causa de redução da pena está reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de drogas. E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6 a 2/3) devem ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que envolvam o caso concreto, podendo variar dentro do seu campo de incidência. Essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder.

Ao julgador compete a análise do impulso, do fator determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente ocasional, ou mesmo, se vem tomando aquela conduta como estilo de vida, para que possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa de redução” (TJSP, Ap. 0003548-97.2014.8.26.0210, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Luiz Antonio Cardoso, j. 30.07.2019).

O regime de cumprimento de pena adequado, por se tratar de crime equiparado ao hediondo, é o inicial fechado. Nesse panorama: “O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto acerto, não só por previsão legal artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 como, também, pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e social. Tanto é que o delito é equiparado aos hediondos.

O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os

mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais.

Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.

Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas, considerado o § 4º, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem dúvida, crime grave.

Mas há os considerados hediondos.

Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo, absolutamente intolerável.

Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?

O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a cocaína e o 'crack', por exemplo, além de causarem dependência, destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances de recuperação. Bem por isso que se trata de crime hediondo.

A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.

O legislador, com a edição da Lei nº 11.343/06, passou a punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados.

Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.

Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que menos os preocupa" (TJSP, Ap. 0000555-39.2016.8.26.0557, 15ª C.D.Públ., Rel. Des. Poças Leitão, j. 01.02.2018).

Por outro lado, é vedada a concessão de sursis ou substituição por pena restritiva de direitos, pela ausência dos requisitos subjetivo e objetivo. Ressalto, quanto tal aspecto que, não obstante a decisão tomada no HC 97.256/RS, do STF, que não possui cunho vinculante, com a devida vênia, não se verifica compatibilidade lógica da pena restritiva com a natureza da infração, sendo que deveria a defesa fazer prova de que o Acusado possui condições da substituição da pena corporal, o que não é afastado nem mesmo diante da Resolução nº 5/2012 do Senado, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, porquanto esta deve se dar respeitando parâmetros preestabelecidos pela lei, notadamente porque o artigo 5º, inciso XLIII, da CF/88 determinou regime mais rigoroso na reprimenda de crimes hediondos e equiparados.

Relevo, ainda, que a disposição do artigo 44 do Código Penal, que trata da conversão de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não é de aplicação automática, pois elenca os requisitos legais para tanto. Ali, em seu inciso III, estabelece que somente é aplicável a comutação quando a conduta social do réu, além dos motivos e circunstâncias do delito, forem favoráveis. A simples prática do narcotráfico, este o flagelo de nossa sociedade, indica o sujeito ativo do crime como pessoa portadora de péssima conduta social, sendo que os motivos e circunstâncias do crime são, evidentemente, desfavoráveis. Para isso, basta se ter contato com um usuário de entorpecente para se verificar a miséria que se tornou sua existência (e de sua família), tão-somente pelo consumo daquilo que é oferecido pelo traficante (ainda que seja um "pequeno" traficante).

Para o crime de narcotráfico, circunstâncias como primariedade, bons antecedentes ou emprego lícito (sendo que o Réu não é possuidor de nenhum destes predicados)

servem para fixar a pena aplicada, bem como, quando o caso, o critério redutor. Contudo, não viabiliza a conversão em pena restritiva ou mesmo a fixação em regime que não o fechado, em vista dos diplomas legais acima citados, pois insuficiente à repressão e prevenção desta infração equiparada à crime delito hediondo. Nesse sentido, lapidar excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, verbis: "Ressalta-se que a decisão apresentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES, em 27 de junho de 2012, reconhecendo e declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 tem seus efeitos 'restritos ao processo e às partes litigantes', não possuindo efeito 'erga omnes', até porque, não afastada pela Suprema Corte a natureza hedionda do delito de tráfico, justificando a imposição do regime mais gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a imposição de regime fechado para o crime de tráfico de entorpecente: HABEAS CORPUS nº 189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012; HABEAS CORPUS 216.265/SP. Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02.06.2012; HABEAS CORPUS 199.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.08.2012; e HABEAS CORPUS nº 225.568/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe. 27.08.2012.

Não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, havendo a necessidade de pronunciar algumas considerações. Com efeito, o Senado, na forma do artigo 52, inciso X da Constituição Federal e com olhos voltados para o julgamento do HC nº 97.256/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, editou a Resolução nº 05/2012, cujo teor é a suspensão da parte que obstaculizava a conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa, inserida no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, com a devida vênia, o traficante, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que não encarcerado.

Em vista o postulado implícito da proporcionalidade (HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos Princípios, Ed. Malheiros), que é uma espécie de norma jurídica derivada do devido, justo e adequado processo legal (FAIR TRAIL), não se mostra razoável que o traficante, condenado por delito equiparado a hediondo (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal) venha a receber tratamento similar ao agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo.

Nesse contexto, pondera-se: de onde viria o numerário para o traficante cumprir a prestação pecuniária? E mais: onde o traficante, disseminador de vício, cumpriria prestação de serviços à comunidade ou entidade pública? Nas escolas? Nas creches? Nos orfanatos? Nos abrigos? Nos hospitais?

Em suma, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal medida atenta contra a efetividade do processo penal na aplicação do justo concreto, atingindo frontalmente o caráter retributivo da reprimenda e a dimensão material ou substancial do 'DUE PROCESS OF LAW'.

Além disso, é válido ressaltar que os recentes arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça indicam que não há ilegalidade na negativa de permuta, quando fundada na multiplicidade e na natureza lesiva das drogas apreendidas, isso porque a conversão da sanção reclusiva não seria suficiente para a prevenção e a repressão do delito denunciado (HC 204115 / MG - Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA - DJe 15/02/2012). E, na espécie, como foram apreendidas porções consideráveis de 'maconha', a aplicação de pena alternativa encontra óbice na exegese do artigo 44, inciso III, do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do exercício da atividade ilícita" (TJSP, Ap. 0005407-56.2011.8.26.0210, 4ª C.D.Crim., Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 18.12.2012).

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do CPP, porquanto o crime apurado é classificado como vago, assim entendido aquele que tem por sujeito passivo a sociedade, destacando, outrossim, que não se comprovou qualquer dano causado em

sujeitos passivos secundários (pessoa submetida aos riscos da lesão).

III. Isto posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência, CONDENO o Réu MARCOS ROBERTO APARECIDO SCHENTL, qualificado nos autos, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, com correção monetária a partir do fato delituoso, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado, vedadas a substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Diante da pena aplicada, em regime inicial fechado em razão da equiparação à hediondez, por seus péssimos antecedentes e ainda por sua reincidência, o Réu, descontente com a decisão, deverá aguardar o julgamento do recurso preso, mantendo, então, sua prisão cautelar, sem prejuízo da apelação, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois nada justifica que, preso em flagrante, fosse colocado em liberdade depois de condenado. São devidas custas na forma da lei, delas ficando o Réu isento por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

P.R.I.C.

Guaíra, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA